

1511921-76.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fernanda Salvador Veiga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... definitivamente por delito anterior de roubo majorado (FA de fls. 107/111 e certidão de fls. 112/113 - autos nº 0101812-13.2015.8.26.0050 - 9ª Vara Criminal da Capital/SP), aumento a pena em 1/6 (um sexto), que atinge 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

No que tange à agravante da calamidade pública, curvo-me ao entendimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1511921-76.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511921-76.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134591/2020 - 91º D.P. CEASA, 11698038 - 91º D.P. CEASA, 2350/20/357 - 91º D.P. CEASA, 2134591 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS SANTOS DO ROSARIO e outro

Vistos.

MARCOS SANTOS DO ROSÁRIO e FELIPE SANTOS NEVES, qualificados nos autos, foram denunciados e se veem processados como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV,

c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, no dia 03 de junho de 2020, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, por volta das 02 horas, na estação metroviária situada na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, n. 540, Barra Funda, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para eles, um corrimão de alumínio, com aproximadamente três metros de comprimento, avaliado em R\$ 3.000,00 (três mil reais), pertencente à Companhia do Metropolitano de São Paulo (fls. 19).

Segundo a denúncia, na data e local acima mencionados, os réus, de comum acordo, decidiram subtrair para eles o corrimão de alumínio fixado no interior da estação de Metrô Barra Funda, oportunidade em que romperam as conexões que fixavam o corrimão à parede e chão, subtraindo-o para eles.

Entretanto, agentes metroviários escutaram um barulho vindo do mezanino da estação, deparando-se, na sequência, com os réus empreendendo fuga em poder do mencionado corrimão, sendo perseguidos e detidos nas proximidades do Memorial da América Latina.

Por tais motivos, foram os réus presos em flagrante delito.

A denúncia foi regularmente recebida em 10 de junho de 2020, tendo sido determinada a citação dos acusados.

Citado pessoalmente (fls. 119), o réu Marcos Antonio ofertou resposta à acusação (fls. 128/132), a qual não teve o condão de ensejar sua absolvição sumária, razão pela qual houve a ratificação do recebimento da denúncia em relação a ele (fls. 137).

Frustrada a citação pessoal (fls. 120), o réu Felipe foi citado por edital (fls. 164/165) e, não tendo comparecido em juízo ou constituído defensor, nos termos do artigo 366 do CPP, foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional em relação a ele (fls. 169).

Em audiência de instrução, debates e julgamento (réu Marcos), foram ouvidas três testemunhas comuns. O acusado deixou de ser interrogado, na medida em que decretada sua revelia na solenidade, porquanto mudou de endereço sem informar ao Juízo (fls. 211) e não compareceu à audiência (fls. 224/225).

Em alegações finais, a representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito descrito na denúncia restaram comprovadas, requereu a condenação do réu nos termos da exordial. Quanto à dosimetria da pena, almejou o reconhecimento das duas qualificadoras descritas na inicial e das agravantes da reincidência e de o crime ter sido cometido durante estado de calamidade pública. Ao final, pugnou pela fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena (fls. 256/258).

A defesa do réu, por seu turno, sustentou a fragilidade probatória e postulou a absolvição do réu. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, pugnou: pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, dada a ausência de perícia e da qualificadora do concurso de agentes, porquanto não comprovado; pela fixação da pena-base no mínimo legal, na primeira fase e pela diminuição máxima da pena, dada a tentativa do delito. Ao final, almejou a fixação do regime inicial aberto, com o reconhecimento do direito de o réu recorrer em liberdade (fls. 263/269).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do réu pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes.

Com efeito, ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia estão satisfatoriamente comprovadas, salvo quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo.

A materialidade do delito restou comprovada pelos: auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 05/06), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Ademais, a autoria é incontroversa.

Na fase policial, ao ser interrogado sobre os fatos, o acusado reservou-se ao direito constitucional ao silêncio (fls. 17).

Em juízo, deixou de ser interrogado, porquanto revel (fls. 224/225).

Por sua vez, a testemunha Gideon Ferreira Silva, agente de segurança do metrô, narrou que, no dia dos fatos, estava trabalhando à noite na estação de metrô Barra Funda, com seu colega de trabalho próximo ao mezanino, quando ouviram um estrondo, como algo se rompendo. De imediato, visualizaram dois indivíduos correndo, um deles carregando um corrimão nas costas e o outro o acompanhando. Tratava-se de um material de alumínio grosso. Passaram a persegui-los e obtiveram êxito em detê-los na Av. Álvaro Soares. Somente perderam os indivíduos de vista por segundos, após eles descerem as escadas da estação de metrô até chegarem à avenida, mas logo voltaram a visualizá-los. O indivíduo que carregava o corrimão era pessoa baixa, de aproximadamente 1,60m. O outro indivíduo era mais alto, de aproximadamente 1,80m e pardo. Acredita que ambos os indivíduos estavam em situação de rua.

A testemunha Flávio Soares Pimentel, agente de segurança do metrô, narrou que, no dia dos fatos, estava em plantão com seu parceiro, quando ouviram um barulho, um estrondo como do rompimento de um ferro. Ao verificarem, visualizaram um rapaz empreendendo fuga, carregando uma barra de alumínio nas costas. A barra possuía aproximadamente três metros. O indivíduo desceu a escadaria do metrô e, embaixo das escadas, outro indivíduo se juntou a ele e empreenderam fuga. O réu Marcos foi detido em frente ao memorial da América Latina. Esclareceu que a barra de ferro que o réu carregava ficava em um corrimão do metrô. Foram capturadas imagens da conduta criminosa, as quais estão em posse do metrô. Chegou a visualizar as imagens em delegacia, nas quais pôde observar que os indivíduos utilizaram uma barra de madeira, de cerca de 1,5 metros, para destacar a barra de ferro. Foi Marcos, de estatura mais baixa, quem retirou a barra de ferro. O outro rapaz o ajudava, segurando a barra na outra extremidade. Ambos foram perseguidos até serem detidos. Marcos e Felipe nada falaram no momento da prisão em flagrante. Pareciam ser pessoas em situação de rua. Sabe que houve perícia realizada no local.

A testemunha Paulo Ramiro Souza Gomes, supervisor de segurança do metrô, narrou que, na data dos fatos, estava trabalhando em outra estação, somente tendo feito apoio no acompanhamento dos acusados até à delegacia. No momento da prisão, os réus admitiram os fatos. Tratava-se da subtração de um corrimão de alumínio, de cerca de três metros, da rampa de acesso sul da estação Barra Funda. Os indivíduos utilizaram-se de um pedaço de madeira para retirar tal objeto. Sabe que foram produzidas imagens do delito, mas não visualizou todas elas, somente uma parte. Nas imagens, era possível visualizar ambos os acusados praticando o delito, fazendo uma

espécie de alça de apoio com o pedaço de madeira utilizado. O local foi isolado e realizada perícia.

De todo o conjunto probatório carreado aos autos, é certo que a autoria do delito deve ser atribuída ao réu Marcos, visto que as provas coligidas no decorrer da instrução processual restaram robustas o bastante para superar a presunção constitucional de inocência.

Nesse sentido têm-se: auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 05/06), bem como pela prova oral colhida nos autos, os quais comprovam a materialidade e autoria do delito.

No mais, fato é que o acusado Marcos foi flagrado pelas testemunhas Flávio e Gideon correndo na estação de metrô, em posse do corrimão de ferro recém removido do local. As testemunhas, outrossim, mantiveram o réu sob campo de visão praticamente todo o tempo e efetuaram sua prisão em flagrante na via pública.

Destarte, as testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório foram uníssonas ao afirmar que puderam visualizar imagens do delito em delegacia, nas quais foi possível visualizar o réu, com suficiente nitidez, praticando a conduta delitiva.

Ademais, a prática da subtração do corrimão da estação pelo réu e seu comparsa pode ser visualizada no vídeo indicado no link de fls. 229.

O réu, revel, não apresentou sua versão acerca do ocorrido.

Desse modo, não resta dúvida de que, no período e local narrados na denúncia, o acusado, na companhia do corréu (processo suspenso em relação a ele - fls. 169), subtraiu, para eles, um corrimão de alumínio pertencente à Companhia do Metropolitano de São Paulo.

A qualificadora do concurso de agentes confirmou-se, diante dos relatos das testemunhas, que puderam visualizar nas imagens do delito a participação de dois indivíduos, bem como diante da circunstância da prisão do réu, que fora surpreendido logo após a subtração da res, em companhia de outro agente. No mais, o vídeo de fls. 229 confirma aludida qualificadora.

Por outro lado, a qualificadora da destruição de obstáculo não restou demonstrada.

Conforme entendimento do C. STJ, a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser comprovada mediante exame pericial, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade da realização do laudo.

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. QUALIFICADORAS MANTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, inciso I e II, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.513.004/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/10/2015, DJe 7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 26/3/2015. 2. No caso, considerando o decurso de prazo entre o fato delitivo e o exame, foi confeccionada perícia indireta dos vestígios no local do crime, na qual foi atestado que a janela do alçapão da obra estava parcialmente danificada e que o cadeado estava no chão totalmente destruído, o que implicou reconhecimento do

arrombamento, além de ter sido constatado que a escalada seria a única maneira de ingressar no imóvel. Importa destacar, ainda, que a perícia restou assinada por dois peritos. 3 Além do auto de constatação, a incidência das qualificadoras foi reconhecida com fundamento em testemunhos e pela confissão do réu - que admitiu durante o inquérito e em juízo ter arrombado parcialmente uma janela e quebrado um cadeado, além de ter escalado o muro do imóvel -, elementos probantes admitidos pela jurisprudência desta Corte Superior para a incidência do inciso art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 573.801/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020) grifei

In casu, conquanto as testemunhas tenham dito que o local foi periciado, em buscas no sistema do IC, não foi possível obter o laudo pericial (fls. 236, 237, 247 e 248/249), embora tal providência fosse plenamente possível.

Finalmente, fundamental o reconhecimento da modalidade tentada do delito, uma vez que o crime não fora consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Consoante restou demonstrado, os agentes do metrô, após ouvirem um estrondo, visualizaram o imediato momento que seguiu a subtração da coisa, perseguindo os furtadores e os prendendo na via pública, ainda na posse da res.

Todavia, considerando o iter criminis percorrido, uma vez que o réu e seu parceiro alavancaram o corrimão, subtraíram o objeto de ferro e chegaram a correr em posse do bem, sendo, contudo, perseguidos, a diminuição deverá se dar em um terço (1/3).

Assim, a conduta do réu encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Uma vez que inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do réu ou extinga a sua punibilidade, reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

No que tange à primeira fase, uma vez favoráveis ao réu as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal, fixo a pena no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Quanto à segunda fase de dosimetria da pena, dada a reincidência do acusado, condenado definitivamente por delito anterior de roubo majorado (FA de fls. 107/111 e certidão de fls. 112/113 - autos nº 0101812-13.2015.8.26.0050 - 9ª Vara Criminal da Capital/SP), aumento a pena em 1/6 (um sexto), que atinge 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

No que tange à agravante da calamidade pública, curvo-me ao entendimento que parece se mostrar majoritário na jurisprudência, para afastar referida agravante, descrita no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porquanto não demonstrado que o réu e seu comparsa aproveitaram-se do momento calamitoso para a prática da infração penal (circunstância subjetiva).

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTUDO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitativa (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC

632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)" grifei

Na terceira fase, em virtude da tentativa, em observância ao art. 14, inciso II, do CP, reduzo a pena do acusado em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis por ele percorrido, tornando a pena definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O valor do dia-multa será o mínimo legal (1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos), ante a condição econômica do réu, haja vista que inexistem elementos a justificar a fixação acima deste patamar.

Embora o crime imputado ao réu tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, na medida em que é reincidente pela prática de roubo majorado, não faz jus a quaisquer benefícios, que, além de socialmente inadequados, seriam manifestamente insuficientes para a prevenção e reprovação da conduta praticada.

Considerando a reincidência do acusado, a pena imposta e o fato de lhe serem favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, ele iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto (Súmula 269 do C. STJ).

Por outro lado, acerca da detração penal na sentença condenatória, considerando a pena aplicada (1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão) e o tempo de custódia cautelar (de 03 de junho de 2020 a 4 de dezembro de 2020, fls. 01 e 161/163), conclui-se que o réu cumpriu o lapso objetivo para fins de progressão (30%, artigo 112, IV, da LEP); assim, inexistindo notícia de prática de falta grave, progrido-o ao regime aberto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado MARCOS SANTOS DO ROSÁRIO, qualificado às fls. 11, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto (já progredido ao aberto nessa data, dada a detração realizada) e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade, considerando que responde solto ao processo e não há razões que justifiquem a decretação da sua prisão preventiva.

Transitada esta em julgado, lancem o nome do sentenciado no rol dos culpados e oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do art. 15 da Constituição Federal.

Custas na forma da lei, consignando-se que, nesta oportunidade, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

P. R. I. C.

São Paulo, 21 de julho de 2021.

FERNANDA SALVADOR VEIGA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA